

1522592-42.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522592-42.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522592-42.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181324/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 25951995 - 101º

D.P. JDIM IMBUÍAS, 2181324 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN NEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

RYAN NEVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, no dia 05 de julho de 2022, por volta de 13h45min, na Luigi Russolo, nº 58, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca da Capital, guardava e vendia, para fins de traficância e consumo de terceiros, 60 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 17,3g (dezessete gramas e trezentos miligramas), 45 porções de cocaína, pesando 8,1g (oito gramas e cem miligramas), e 33 porções de maconha, pesando 49,7g (quarenta e nove gramas e

setecentos miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 6,00 (seis reais) - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18, laudo de constatação de fls. 24/27.

Segundo o apurado, policiais civis realizavam diligência no local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram RYAN NEVES retirar uma pochete detrás de um carro, entregar algo para um indivíduo que estava em uma bicicleta e tal pessoa partir rapidamente.

Os policiais, então, realizaram a abordagem e descobriram que, no interior da pochete que estava próximo aos seus pés, RYAN NEVES escondia as drogas acima descritas destinadas ao comércio espúrio, além da quantia de R\$ 6,00, em espécie. Na ocasião, o denunciado informalmente admitiu a traficância.

As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, o movimento típico de venda de drogas, a variedade e quantidade de entorpecente apreendido e a apreensão de dinheiro, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia (fls.1/3), foi ela recebida no dia 27 de setembro de 2022 (fls.112/115). O acusado foi citado (fls.67), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.68/70; 71/73), subscrita pela defesa constituída. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de dezembro de 2022, às 16:30 horas (fls.112/115), na modalidade remota. Durante a instrução da causa dois policiais civis foram ouvidos e o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Não se opôs a aplicação do redutor, carga máxima, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade e recurso em liberdade.

A nobre Defesa, por sua vez requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII. Subsidiariamente, aplicação do redutor em carga máxima, regime aberto, substituição da pena e recurso em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.5); o boletim de ocorrência (fls.9/11); o auto de exibição/apreensão (fls.18); o termo de interrogatório (fls.12); o termo de depoimento (fls.6/8); o auto de qualificação (fls.15); o laudo pericial (fls.63/65); bem como as folhas de antecedentes (fls.34/35;58).

E o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 18 ) e dos laudos de constatação provisória (fls. 24/27 ), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls.63/65 ), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, vejamos.

O Policial Alisson reconheceu o acusado de trafico de entorpecentes. Estava junto com seu parceiro diligenciando pela área da delegacia e ao chegar no local dos fatos, avistou uma movimentação que parecia de trafico. Nisso assistiu o acusado entregando algo a um individuo de bicicleta que saiu do local rapidamente. Fizeram a abordagem e com ele nada foi localizado mas próximo dele, meio metro, localizaram uma pochete com aproximadamente 60 pedras de crack. 45 saquinhos de cocaína, maconha e 6 reais em dinheiro. A droga estava fracionada para venda. Ficou uns 10 minutos de campana e nesse período viu o acusado mexendo nessa pochete. Foi por isso que a encontraram. Ele admitiu informalmente o trafico de drogas. Acredita que ele more pelas redondezas, no Jardim das Imbuías. Não o conhecia antes. Nenhum caderno de apontamento foi apreendido. Ele confessou o crime para o depoente. Policial Eliezer também reconheceu o acusado de uma ocorrência de trafico em uma rua próxima a delegacia, local que é um ponto de drogas. Ficou observando o local e

viu quando um rapaz de bicicleta passou e ele entregou algo. Ele foi atrás de um carro e se abaixou. Na sequência ele voltou e entregou a um rapaz de bicicleta. Uma bolsa com entorpecentes foi encontrada atrás desse carro, bem próxima a ele. Uma media de 40 porções de cada tipo de droga mais uns trocados. Não se recorda o que ele disse. Não se recorda se alguém compareceu ao local para se dizer parente dele. Não pode ver se houve a troca de dinheiro e drogas mas viu que ele pegou algo na mão. Ficou um pouco de campana, cerca de 10 a 15 minutos. Não se recorda se havia apontamentos com ele.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). O réu, por sua vez, negou a prática delitiva e trouxe uma versão completamente desamparada de base probatória, vejamos

Ryan tem 19 anos. Mora com a mãe, o pai e o irmão. Mora na rua Manoel Paixão Ribeiro, 259. Quando foi preso trabalhava como ajudante de pedreiro com o pai. Não mora próximo do local em que foi preso. Nunca teve problemas com a justiça, nem quando era menor. Não usa entorpecente. Não são verdadeiros os fatos. Estava ajudante com a tia do mercadinho. O nome dela é Regina. Estava limpando a calçada dela. Conheceu o filho dela porque o padrinho mora ali próximo. Estava passando uns dias com o padrinho. O nome dele é Jefferson e ele mora próximo ao local. Não conhecia os policiais. A tia tem um mercadinho, mercadinho da Tia. Entregou um troco de dinheiro para um rapaz de bicicleta que havia comprado refrigerante, molho de tomate e macarrão no mercado. Na delegacia foi ameaçado por outros policiais. Os policiais ouvidos na data de hoje não o ameaçaram. Viu o momento que os policiais encontraram a droga que estava debaixo de um carro. Em momento algum foi perto desse carro. O rapaz de bicicleta lhe deu 20 reais. Foi no mercado, pegou o macarrão, o refrigerante e o molho de tomate. Entregou tudo ao rapaz junto com o troco. Estava longe do carro mas não saberia dizer a quantos metros. A tia foi informar o padrinho do que havia ocorrido. Não foram os policiais ouvidos hoje que o prenderam.

Como se vê, sua versão é inverossímil e não está de acordo com a verdade. Seria facilmente apta a ser comprovada, bastando para tanto que as pessoas mencionadas por ele viesse depor em juízo, o que não ocorreu.

De outra parte, o fato criminoso veio bem comprovado não só no que diz respeito a materialidade como também no que tange a autoria pois não é tangível que os policiais envolvidos na ocorrência estivesse fazendo um complô contra um jovem

trabalhador.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, nada a considerar.

Em terceira fase, nos termos das ponderações trazidas pelo Ministério Público e pela Defesa, ainda que em tese subsidiária, também entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno RYAN NEVES, RG: 53008235, nascido em 16/10/2003, filho de Monica Neves, ,

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 18). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06;

Transitada esta em julgado tornem conclusos para a designação de data para audiência admonitória.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Isento de custas.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA